

1502711-13.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Contou que o acusado alegou que realizava o tráfico de drogas porque estava desempregado e passava necessidades. Afirmou que não o conhecia anteriormente. Esclareceu que entraram no conjunto do BNH por saberem que ali há vários pontos de tráfico de drogas. Não era uma investigação, mas sim uma diligência de rotina. Já foram realizadas diversas prisões naquela região. Disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502711-13.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502711-13.2021.8.26.0536 - Controle n.º 593/21

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEVERSON ALVES GULONE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

CLEVERSON ALVES GULONE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 13h40min, na Rua Vergueiro Steidel, em frente ao n.º 363, bairro Embaré, neste município e comarca, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava 6 (seis) porções de crack, com peso aproximado de 2,8 gramas, e 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína, com peso aproximado de 28,8 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão p. 5, fotografia de p. 16 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de p. 26.

Diz a denúncia que policiais civis, em diligências pela área que é conhecido ponto de tráfico, avistaram o acusado em movimentação típica de venda de drogas. Os policiais observaram, por algumas vezes, a seguinte movimentação: o acusado recebia dinheiro de transeuntes, caminhava até um veículo estacionado de onde pegava algo que estava guardado embaixo e retornava para entregar o que havia pego aos compradores, que deixavam o local.

Os policiais decidiram abordá-lo. Realizada a busca pessoal, constataram que o acusado trazia com ele a quantia de R\$ 10,00. Em busca pelo local, constatou-se que

o réu guardava naquela região apontada 6 (seis) porções de crack e 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína.

Diz, por fim, a petição inicial que a finalidade da mercancia ilícita das drogas ficou evidenciada pelos seguintes elementos: 1) A quantidade e variedade de drogas apreendidas, cocaína e crack, individualmente embaladas à venda; 2) A movimentação típica de tráfico de drogas efetuada pelo acusado, que foi observada pelos policiais em campana; 3) A localização de dinheiro em poder do acusado (pp. 95/96) Notificado o réu (p. 115), foi oferecida a defesa prévia de pp. 118/119. Presente justa causa para o processamento da ação penal, foi recebida a denúncia (pp. 122/124), citando-se o acusado (p. 193).

Na instrução foram ouvidas três testemunhas (pp. 209/210 e 249/252), procedendo-se ao interrogatório (pp. 249/252).

Em alegações finais, por memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. No tocante à reprimenda, pleiteou a majoração da pena-base em virtude dos maus antecedentes e da quantidade e nocividade das drogas apreendidas. Outrossim, sustentou não ser possível a incidência da causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 por ser o réu reincidente específico e se dedicar a atividades criminosas. Por fim, pretendeu a aplicação de regime inicial fechado e alegou não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (pp. 257/265).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações escritas, em preliminar, pleiteou a declaração incidental de inconstitucionalidade do crime de tráfico de drogas, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, com risco meramente presumido, e não ofender concretamente um bem jurídico, afrontando, portanto, o princípio da presunção da inocência, pretendendo, pois, a absolvição por se tratar de fato atípico. No mérito, requereu a absolvição sustentando não existir prova suficiente para a condenação, uma vez que o conjunto probatório se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que apresentaram contradições. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação em patamar máximo da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Por fim, requereu a concessão de regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (pp. 269/288).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de declaração de inconstitucionalidade pela via difusa, invocada pela Defesa, não merece acolhida.

Com efeito, não há como reconhecer que o tráfico de drogas seja conduta atípica em razão da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, como alegado.

Outrossim, e como se sabe, a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato é questão há muito consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Apura-se aqui conduta delituosa que afronta e põe em risco a saúde pública, evidenciando-se patente o risco social, bem como se revela potencial e abstrato o dano decorrente do comércio ilegal de entorpecentes, afetando, e muito, o bem jurídico protegido.

Não se poderia deixar de levar em conta que o tráfico de drogas desassossega a sociedade, compromete a paz social e fulmina a saúde pública, pois não apenas destrói o futuro de muitos jovens e desintegra famílias por conta da dependência química, mas também alimenta toda uma cadeia de crimes violentos, notadamente crimes contra o patrimônio e contra a vida.

Trata-se, por certo, de norma penal que tutela a saúde pública e não há dúvida que deve o Estado criminalizar o tráfico de drogas, já que é justamente a saúde pública que se coloca em risco em razão de tal conduta.

Essa situação não só é penalmente relevante, como também tipifica crime equiparado a hediondo, conforme disposição constitucional, exigindo repreensão estatal ainda maior e rigorosa, como bem se sabe.

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"...Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da

criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação..." (HC 102087, Relator(a): Celso De Mello, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, DJe-159 divulg 13-08-2012 public 14-08-2012 republicação: DJe-163 divulg 20-08-2013 public 21-08-2013 Ement Vol-02699-01 PP-00001).

Nesse sentido também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INOCORRÊNCIA CONDUTAS QUE LESIONAM A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ COLETIVA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. 1. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico, não havendo que se falar, assim, na inconstitucionalidade de tais ilícitos. Precedentes do STF..." (HC 351.325/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Por tais razões, rejeito a preliminar invocada pela Defesa.

No mérito, o pedido inicial é procedente.

A materialidade do crime está satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (p. 5), pelo auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (p. 26) e pelo laudo de exame toxicológico (pp. 152/154).

A autoria dos fatos delituosos também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, e apesar da acusação que lhe era dirigida, o acusado manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram sua prisão (p. 8).

Em juízo, ao ser interrogado, afirmou que já foi preso e processado pelo crime tráfico de drogas. Nada tem contra os policiais e os conheceu em razão destes fatos. Contou que estava na barraca do Sr. José, que vende ovos. Notou quando um policial sem farda parecia procurar por algo. Perguntou ao homem se buscava algum endereço e ele se apresentou como policial. Foi rendido pelo policial e colocado deitado no chão. Questionado sobre o que fazia naquele local, respondeu ao policial que ali estava para comprar ovos. Chegou outro policial e, após conversarem entre eles, o primeiro policial o questionou se possuía passagem, respondendo afirmativamente. Depois de certa procura, o segundo policial encontrou alguma coisa e atribuiu-lhe a propriedade. Os policiais o algemaram e perguntaram onde morava.

Em seguida, colocaram-no em uma viatura, mas havia outros policiais em um outro veículo. Ao pedirem seu documento de identificação, informou que o trazia no bolso da calça. O mesmo policial que efetuou sua detenção pegou sua carteira com o documento. Foi levado à delegacia. Esclareceu que o policial que realizou sua detenção é o agente de barba ouvido em audiência, enquanto o outro policial ouvido em juízo é aquele que encontrou as drogas. Referiu ter permanecido deitado e só conseguiu ver que o objeto encontrado era uma sacola. Nada sabia sobre o seu conteúdo. Também não conseguiu ver o local que o policial encontrou esta sacola. Afirmou que em nenhum momento saiu de perto da barraca de ovos. Havia outras pessoas no local, porém estavam mais distantes. O comerciante presenciou toda a ação. Não soube estimar o tempo que permaneceu nesta barraca. Não chegou a pagar pelos ovos. Desconhece qualquer motivo para que os policiais quisessem incriminá-lo. Informou que não os acompanhou até sua casa. Reside próximo ao local em que foi

detido. Trabalha na feira livre como funcionário numa barraca de utensílios domésticos. Naquele dia, antes de ir trabalhar, sua irmã havia pedido para comprar ovos, mas esqueceu de comprá-los. Não sabe o motivo pelo qual os policiais foram à sua casa. Disse que passou o endereço para que colocassem no registro da ocorrência. Afirmou que nunca tinha visto estes agentes anteriormente. Alegou que alguma vizinha que presenciou a abordagem avisou sua irmã sobre a prisão, mas não sabe quem foi tal pessoa. Esclareceu que foi preso anteriormente porque estava envolvido com tráfico de drogas em sua casa no bairro do BNH. Os responsáveis por sua prisão atual não são os mesmos agentes que o prenderam da outra vez. Disse que trabalha de domingo a sábado, com folga às segundas-feiras, e recebe R\$ 45,00 por dia trabalhado. É pai de três filhas que contam 16, 15 e 10 anos de idade. As mais velhas residem com a mãe e a caçula mora com ele e sua irmã. Faz uso de maconha desde os seus 20 anos de idade. Conseguiu apenas reduzir o consumo do entorpecente. Sua família tem conhecimento de seu vício. Concluiu a oitava série enquanto estava na prisão. Não continuou os estudos para cuidar de sua filha. Reside na casa de seu avô. Esclareceu que as viaturas eram da cor verde e vermelha, mas não sabe a marca e nem o modelo. O dinheiro que portava era uma única nota de R\$ 10,00 reais (gravação audiovisual pp. 249/252).

Todavia, e ainda que tenha o réu negado a prática do crime que lhe é imputado, indiscutível é a procedência da ação penal.

Lucas Valente, policial civil, informou trabalha na delegacia especializada e conhecem aquele local como ponto de venda de drogas do BNH. Relatou que estavam de passagem e observaram uma atitude suspeita do réu. Realizaram monitoramento por cerca de vinte ou trinta minutos e perceberam quando duas pessoas entregaram algo ao réu, o qual, após pegar um objeto embaixo de um veículo estacionado, entregou alguma coisa para os transeuntes. Após observarem esta movimentação ocorrer duas vezes, resolveram abordá-lo. Encontraram R\$ 10,00 em seu poder, além de drogas no local onde ele mexia. As drogas estavam guardadas próximo ao pneu do veículo estacionado na via. Contou que o acusado alegou que realizava o tráfico de drogas porque estava desempregado e passava necessidades. Afirmou que não o conhecia anteriormente. Esclareceu que entraram no conjunto do BNH por saberem que ali há vários pontos de tráfico de drogas. Não era uma investigação, mas sim uma diligência de rotina. Já foram realizadas diversas prisões naquela região. Disse não se recordar se entrou pela Rua Vergueiro Steidel ou pela Rua Pirajá da Silva. Estavam em dois policiais. Após identificarem a atitude suspeita, estacionaram a viatura fora do BNH e caminharam cada qual por uma rua. Esclareceu que não há como as viaturas se aproximarem muito, pois os informantes conhecem os veículos e avisam os criminosos. Assim que se aproximaram começou a ouvir os gritos de “água, água”, que é a forma pela qual os informantes avisam que a Polícia chegou. Expôs que estavam cerca de cinquenta metros do réu quando avistaram a traficância. Disse que ele e seu parceiro estavam em ângulos diversos visando assegurar a abordagem. Informou que os transeuntes não foram abordados para que pudessem chegar até o réu com maior discrição. Caso contrário, os águas alarmariam a todos e não conseguiriam realizar a prisão. Esteve na presença do defensor enquanto estava na casa do réu. Não se recordou o que conversaram. Disse que entraram na residência com autorização da irmã do acusado para procurar o documento de identidade do réu, que já estava preso em situação de flagrante. Afirmou que não encontraram drogas na residência. Não conhecia o nome do acusado de outras investigações. Foi o réu que informou o endereço residencial. A viatura utilizada é um corsa verde descaracterizado (gravação audiovisual pp. 209/210).

Marcelo Inácio Vasconcelos da Silva, policial civil, narrou que foram até o local, que é conhecido ponto de tráfico de drogas. Estavam com uma viatura descaracterizada e avistaram o réu em atitude suspeita, relatando que, por duas vezes, viram que pessoas entregaram algo ao acusado, que em seguida dirigia-se a um veículo estacionado. Ele se abaixava e retornava para entregar algum objeto para as pessoas que o aguardavam e que foram embora dali logo após. Relatou que desembarcaram da viatura e realizaram um cerco a pé, procedendo a abordagem. Afirmou que o acusado não teve reação. Com a busca realizada, encontraram os entorpecentes. Em poder do réu localizaram dez reais. Esclareceu que seu parceiro

encontrou o entorpecente próximo a um carro estacionado. Enquanto isso, permaneceu com o réu, que já estava algemado. Disse que a abordagem se deu bem no meio do conjunto habitacional do BNH, numa espécie de praça. Contou que colocaram a viatura no local em que os moradores estacionam veículos. Atuaram rapidamente na campana e na abordagem, pois assim os olheiros não os notaram, pois caso contrário alertariam que a Polícia ali estava, e como normalmente acontece. Apreenderam 5 pedras de crack e 30 porções de cocaína. O réu se mostrou tranquilo e apenas disse que estava necessitando. Foram até a casa do acusado para pegar seu documento de identificação. O réu residia próximo ao local dos fatos. Não o conhecia anteriormente. Esclareceu que entraram no BNH pela Rua Pirajá da Silva e estacionaram a viatura no interior do conjunto habitacional. Após desembarcarem do veículo, cada policial foi por um lado, a pé, para realizar a abordagem. Não sabe por qual rua ele e seu parceiro seguiram. Tais abordagens fazem parte de seu cotidiano como policial. Lembra-se que seu parceiro estava à frente e foi ele quem abordou o réu. Disse que a campana foi realizada a mais ou menos quarenta metros de distância de onde estava o réu. Informou que não abordaram os transeuntes porque não havia tempo, pois em tais diligências precisam agir rápido a fim de prender o traficante, não sendo possível direcionar atenção aos usuários de drogas. Acredita que o réu, antes de ser surpreendido, estava sentado. As drogas se encontravam em uma sacola, cuja cor não se lembrava. Recordou-se do defensor presente na audiência, pois o viu na casa do acusado. Não tem lembranças sobre o que conversaram. Afirmou que entraram na casa do réu porque alguém franqueou a entrada. O acusado permaneceu detido na viatura neste momento. Disse que olharam o quarto do réu e nada encontraram. Informou que não participou de outras investigações que envolvessem o acusado. O réu informou seu endereço residencial. A residência do acusado situa-se no BNH e fica próxima do local da abordagem. Detalhou que a droga encontrada estava perto do acusado, a mais ou menos quinze metros dele. O réu não fazia parte de nenhuma investigação policial (gravação audiovisual pp. 209/210). Nayara Alves Gulone, irmã do acusado, informou que estava em sua residência com seu avô quando o réu chegou do trabalho. Pediu que ele comprasse ovos para o almoço. Quinze minutos depois um policial bateu à sua porta. Quando abriu, um dos policiais a empurrou e invadiu a casa. Foi informada que seu irmão havia sido preso e que precisavam saber onde estavam as drogas. Contou que seu avô foi até a sala e um dos policiais ficou explicando a ele o que estava acontecendo, enquanto outros três policiais foram até o quarto do réu. Eles passaram a revirar o cômodo enquanto perguntavam onde estavam as drogas. Disse que questionou a atitude dos policiais, se havia algum documento que os autorizassem a entrar na casa. Os policiais informaram que não possuíam ordem judicial e que seu irmão já havia sido preso, de modo que estavam ali procurando o restante dos entorpecentes. Afirmou que não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência. Os agentes não perguntaram pelo documento de identificação do réu, apenas diziam que queriam saber onde estavam as drogas. O acusado estava com sua carteira no bolso. Informou que as buscas cessaram porque o defensor chegou ao local. Nada foi encontrado no interior da casa. Soube que os policiais encontraram drogas embaixo de um carro, o qual não chegou a observar. Relatou que o defensor foi chamado pela vizinhança. Ao perceberem que o réu havia sido preso, os vizinhos o acionaram por saberem que era advogado (gravação audiovisual pp. 249/252).

Vê-se, assim, que ao contrário do que sustentou a Defesa, a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório, não sendo possível declarar a absolvição.

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis esclareceram que a abordagem foi decorrente de diligência rotineira que faziam em local que é conhecido ponto de venda de entorpecentes, fundada a suspeita que ali surgiu porque visualizaram suposta venda e entrega de entorpecentes a duas pessoas não identificadas, em distintas ocasiões.

Observaram que o réu recebeu algo das pessoas que com ele mantiveram contato, dirigiu-se até um veículo ali estacionado, notando que ele se abaixava em busca de alguma coisa, que aparentemente entregava às pessoas, que de lá saíram em seguida. Assim, desembarcaram da viatura descaracterizada e seguiram a pé por lados opostos,

cercando o réu e realizando a abordagem. Em revista pessoal, encontraram em sua posse R\$ 10,00, sendo que, embaixo do automóvel estacionado, e para onde o réu se dirigia, encontraram uma sacola contendo crack e cocaína.

Declararam, outrossim, que o acusado admitiu informalmente que estava desempregado e realizava o tráfico por necessidade.

Certo, pois, que a prova revelou que o acusado praticou a conduta descrita na petição inicial e nada nos autos indica que os policiais civis pretendessem incriminar o réu indevidamente, como quis fazer crer.

Esses agentes públicos limitaram-se a narrar o ocorrido, não se tendo indicação alguma de que se trate de situação forjada para incriminá-lo. Quis o réu fazer crer que foi indevidamente acusado, mas essa afirmação cede à análise da prova aqui reunida.

Não há razão para desprezar a prova oral unicamente porque apenas policiais relataram detalhes a respeito da abordagem do réu, localização e apreensão do entorpecente, que certamente era destinado ao consumo de terceiros.

Outrossim, quando coerentes as declarações dos agentes da autoridade, como no caso aqui analisado, não se pode deixar de outorgar habitual valor probatório apenas em razão de sua condição de supostamente possuírem interesse em legitimar seus atos. Cabe à Defesa provar com segurança que tais depoimentos são viciados ou ostentam intenção de prejudicar o acusado.

Deste modo, não se poderia desacreditar o relato de cada qual, uma vez que esses agentes presenciaram a mercancia ilícita, a localização das drogas e a admissão informal do acusado, não se podendo entender como suspeitos àqueles que são investidos de poder para tal função.

Como já se decidiu:

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (HC 87662, Relator(a): Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007).

"... A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário..." (TJSP; Apelação Criminal 1500453-63.2018.8.26.0559; Relator(a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021).

Note-se, ademais, que ao contrário do que alegou a Defesa, os agentes policiais, em idêntico relato, narraram os principais detalhes envolvendo a conduta criminoso aqui apurada, como anteriormente descrito, e não se observa contradições que retirem a credibilidade do contexto probatório.

Com efeito, não se pode entender que apreensão de uma única nota de dez reais (p. 16) possa comprometer a prova aqui reunida somente porque há relato da visualização de duas movimentações de venda. Ora, nada impede que réu tenha dado como troco ao segundo usuário o dinheiro que havia recebido do primeiro, o que, por óbvio, justifica a presença de uma única cédula, destacando-se que a pedra de crack, a depender do tamanho, é comercializada por cinco reais, como normalmente se vê em apuração de crimes desta espécie.

Ainda, e relativamente à alegada contradição quanto ao local onde foi realizada a campana e o lugar no qual a viatura descaracterizada permaneceu estacionada, conforme mencionado pelos policiais, tais abordagens fazem parte de suas rotinas e constantemente realizam prisões naquela área, justamente por trabalharem em uma Delegacia Especializada que visa combater o tráfico de entorpecentes, e terem conhecimento que ali é um ponto de comércio ilícito de drogas.

Compreensível a diferença se considerado o grande número de diligências realizadas diariamente por estes profissionais e as circunstâncias que envolvem a atuação nessa espécie de ação policial.

Todavia, os depoimentos dos policiais civis, no essencial, são uniformes e coerentes, e não justificam e nem autorizam a pretendida absolvição.

Finalmente, no tocante à alegada invasão ao domicílio do acusado e sua família, é certo que as drogas já haviam sido apreendidas e o réu se encontrava algemado no interior da viatura, de maneira que eventual ilegalidade, ainda que fosse reconhecida, em nada comprometeria a acusação.

Nestes termos, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a anulação das provas obtidas a partir da invasão ilegal de domicílio não macula o fato ocorrido anteriormente, qual seja, o da flagrância da acusada em posse de relevante quantidade de drogas ainda em via pública" (HC 679.290/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021).

De outro lado, sabe-se que o réu não está obrigado a dizer a verdade: ao contrário, bem pode pretender alterar a verdade dos fatos, procurando afastar sua responsabilidade penal, justamente para não se prejudicar.

Nestes termos, inaceitável a versão que o réu ofertou, pois quis fazer crer que foi indevidamente acusado pelos policiais civis, que o abordaram enquanto comprava ovos e, por já ter sido condenado por tráfico de drogas, forjaram o encontro das porções de entorpecentes apresentadas à autoridade policial.

Evidente que não há como admitir essa versão, uma vez que a prova revela que as drogas encontradas em razão da diligente ação policial pertenciam ao acusado.

Ressalte-se, ademais, que a irmã do acusado, ouvida como testemunha do juízo e a pedido da Defesa, nada contribuiu para melhor esclarecimento dos fatos delituosos que ao réu são aqui imputados, pois não presenciou a abordagem policial e sequer estava no local.

Evidente, ainda, que a relação de parentesco e afeto que mantém com o réu retira a credibilidade das afirmações que faz com a intenção de ajudá-lo e inequivocamente protegê-lo.

Vale dizer, mais uma vez, do processado não se extrai razão plausível para que os policiais civis criassem diabólico plano visando incriminar o réu, apontando-o como autor dessa espécie de crime.

Seria inacreditável imaginar que os investigadores de polícia elaborassem fantasiosa estória, forjando provas e encontro de drogas, para acusar indevidamente o réu, pessoa que sequer conheciam.

Despropositada, por absurda, essa situação.

A conduta do acusado, como mencionada na petição inicial, que trazia consigo e guardava os entorpecentes para entrega a terceiro, caracteriza o delito de tráfico de drogas, mencionado no artigo 33 da Lei de Tóxicos.

Sabe-se que basta que a droga tenha a finalidade de circulação, ainda que gratuita, diversa do só consumo, o que no caso é evidenciado pela quantidade e variedade da droga apreendida - 06 (seis) porções de crack e 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína - inequivocamente destinadas ao objetivo da mercancia, bem como pela movimentação observada pelos experientes policiais, de venda e entrega de entorpecente por parte do acusado aos transeuntes que o procuravam.

Além disso, a apreensão de dinheiro (R\$ 10,00), naquelas circunstâncias, não deixa dúvidas de que o destino dos entorpecentes era o comércio ilícito.

Registre-se, ainda, que a negativa de autoria se vê desamparada de seguro elemento de prova, razão pela qual não merece crédito algum e sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório.

Procede, portanto, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

O acusado é primário.

Todavia, ostenta condenação definitiva antiga pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0022232-96.2005.8.26.0562 - certidão de pp. 29/30), a qual, ainda que não sirva para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, continua a macular sua vida pregressa e deixa claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos

do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, em razão dos comprovados maus antecedentes, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pena esta que torno definitiva.

Registre-se, também, que não é o caso de ser reconhecida a causa especial de diminuição da pena, prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por expressa vedação legal, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes.

E, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR GERA MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO ADEQUADAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018). 2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas" (AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019)...." (AgRg no REsp 1905160/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 - grifei).

Considerando o quantum da pena aplicada, os comprovados maus antecedentes aqui representados por condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, mas em especial por se considerar a prática de crime equiparado a hediondo, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar CLEVERSON ALVES GULONE, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

O acusado viu convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Como já se reconheceu, os fatos aqui apurados desassossegam a sociedade, comprometem a paz social e fulminam a saúde pública, que se vê assolada pela ação inescrupulosa de traficantes que unicamente almejam o lucro fácil na disseminação do vício.

Forçoso admitir que condenados por essa espécie de crimes não se submetem

voluntariamente a decisões judiciais, sendo pertinente reconhecer que a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas. Lembre-se que o acusado foi preso em flagrante enquanto trazia consigo e guardava razoável quantidade e variedade de drogas em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e ostenta maus antecedentes pelo delito de tráfico de drogas (certidão pp. 29/30).

Desta forma, é de se reconhecer que essa situação não revela que seja ele pessoa de boa conduta social, mantendo vida desregrada e fazendo da criminalidade seu meio de vida.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, o acusado poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenado a cumprir pena em gravoso regime.

Assim, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Considerando que o dinheiro apreendido em poder do réu (p. 101) é inequivocamente fruto da mercancia proscrita, na forma do que dispõe o artigo 63 da Lei 11.343/06 e artigo 91, inciso II, do Código Penal, determino a perda em favor da União.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 7 de fevereiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA